

1500056-40.2022.8.26.0631
Classe: Auto de Prisão em Flagrante
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Fernando Leonardi Campanella
Comarca: Amparo
Foro: Foro de Amparo
Vara: 1ª Vara
Data de Disponibilização: 30/09/2022
... 59" .

Ora, é de pronta inteligência que a perpetração de tráfico denota personalidade inteiramente avessa aos preceitos ético-jurídicos que presidem à convivência social. Tendo isso presente, deve o juiz sujeitar o agente ao mais severo regime prisional.

Acresce ponderar que a concessão de regime aberto ou semiaberto ao autor de tráfico ilícito de substância entorpecente ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Amparo
Foro de Amparo
1ª Vara
Praça Tenente José Ferraz de Oliveira, 55, Amparo-SP - cep 13900-900
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500056-40.2022.8.26.0631 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500056-40.2022.8.26.0631
Classe - Assunto:
Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2033660/2022 - DEL.POL.SERRA NEGRA, 22842999 - DEL.POL.SERRA NEGRA, 226/22/112 - DEL.POL.SERRA NEGRA, 2033660 - DEL.POL.SERRA NEGRA, 2033660 - 01º D.P. AMPARO, 226/22/112 - 01º D.P. AMPARO
Autor:
Justiça Pública
Réu:
JÔNATAS RODRIGUES DA SILVA

Juiz de Direito: Fernando Leonardi Campanella

VISTOS.

JÔNATAS RODRIGUES DA SILVA, qualificado nos autos (fl. 15), foi denunciado pelo

Ministério Público do Estado de São Paulo, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, acusado por ter, no dia 05 de fevereiro de 2022, por volta das 17h00, na Rua Marechal Bitencourt, próximo ao numeral 45, Jardim Ribeirão, nesta cidade e Comarca de Amparo/SP, trazido consigo, com o fim de entrega ilícita ao consumo de terceiros, a título de venda ou de qualquer forma de disseminação de uso, 28 (vinte e oito) porções de "crack", pesando 4,24g, fazendo-se sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (fls. 78/79).

Prisão flagrancial convertida em preventiva (fl. 69/70).

O réu foi solto por força de decisão do C. STJ, exarada em sede de habeas corpus impetrado (fls. 130/133). Alvará cumprido (fls. 142/145).

A denúncia foi recebida em 17/02/2022 (fl. 81).

Devidamente citado (fl. 104), o acusado, por intermédio de sua D. Defensora nomeada (fl. 120), apresentou resposta por escrito a acusação (fl. 113/119), não arrolando testemunhas.

O réu foi colocado em liberdade (fls. 142/145), por força de decisão liminar exarada pelo C. STJ, em sede de habeas corpus (fls. 129/133).

Não sendo o caso de julgamento in limine do feito com a absolvição sumária do acusado, determinou-se a abertura da fase instrutória (fls. 121/122), oportunidade em que foi colhida a prova oral, consistente na oitiva das duas testemunhas arrolada pela Acusação, seguindo-se para o interrogatório do acusado, tudo pelo sistema audiovisual (cf. atas de fls. 160 e 175).

Em sede de memoriais escritos, o D. Promotor de Justiça requereu a condenação do acusado nos exatos termos da denúncia, por entender suficientemente comprovadas autoria e materialidade delitiva. A D. Defensora, por sua vez, pugnou pela absolvição do acusado, diante da fragilidade do conjunto probatório. Subsidiariamente, requereu a desclassificação da imputação original para o crime previsto no artigo 28, caput, da mesma Lei, além de tecer considerações a respeito da pena. (fls. 176/183).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada por intermédio dos autos de exibição e apreensão (fls. 09/10) e de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 11/12), ilustrados por foto (fl. 13), comprovante do importe numérico depositado (fl. 72), bem como e, principalmente, pelo laudo químico-toxicológico realizado nas drogas (fls. 88/90), que confirmou tratar-se de cocaína, como princípio ativo do "crack", substância que causa dependência física ou psíquica, listada na Portaria nº 344/98 - SVS/MS.

A autoria, da mesma forma, não comporta dúvidas.

Vale lembrar em primeiro lugar que o acusado foi preso em flagrante delito, após dispensar um invólucro contendo 28 (vinte e oito) pedras de "crack", embaladas individualmente, prontas para venda, na fuga de uma abordagem.

Assim, a autoria torna-se certa, pois, segundo Rafael Magalhães, apud Tourinho Filho, a prisão em flagrante "é a certeza visual do crime". A expressão também é usada na doutrina clássica por Tostes Malta, na obra "Do Flagrante Delito", 1933, p. 25.

De acordo com HÉLIO TORNAGHI, prender em flagrante é capturar alguém no momento em que comete um crime. Ainda segundo o ilustre autor: "Nunca é demais lembrar que a flagrância talvez seja a prova mais eloquente do crime e da respectiva autoria" ("curso de Processo Penal", 5 ed., 49).

Ademais a análise coligida dos elementos colhidos no caderno investigativo e produzidos sob o crivo do contraditório permite concluir pela responsabilidade penal do réu. Vejamos.

Ivan Cássio Cimenton, policial militar, relatou que havia diversas "denúncias" informando que JONATAS transportava drogas até uma praça, "ponto" de venda de entorpecentes. Naquela data, em patrulhamento, visualizou um indivíduo, na bicicleta, com as mesmas características de JONATAS, que não acatou a ordem de parada, evadindo-se. O depoente saiu ao encalço do acusado, avistando-o arremessar algo no mato, durante o trajeto da fuga. Conseguiu alcançá-lo e abordá-lo, em poder de R\$8,00 em moedas, tendo ele resistido fisicamente. Ao realizar a varredura no mato foi encontrado um invólucro transparente, contendo em seu interior 28 pedras de "crack" embaladas individualmente, tratando-se daquilo que o acusado dispensou. Questionado, ele confessou a propriedade do entorpecente, sustentando ser para o consumo próprio.

Estevão Cassiano Cimenton, colega de farda, confirmou a existência de informações que recaíam sobre a pessoa de JONATAS, no sentido de ser ele o responsável por fazer o transporte de entorpecentes de uma moradia até a "biqueira" do "Matadouro". Sendo assim, naquela data, em patrulhamento casual, avistou o réu, que ao notar a presença da viatura, não obedecendo à ordem de parada, fugiu, dispensando no trajeto em um matagal, um invólucro, posteriormente localizado e identificado contendo 28 porções de "crack" em seu interior. Abordado e contido, o réu estava em poder de R\$8,00.

Assim como havia feito em solo policial (fl. 05), interrogado em juízo, JONATAS confirmou a propriedade das 28 pedras de "crack", as quais havia acabado de adquirir naquele local, alegando, todavia, serem para seu consumo pessoal, negando o abastecimento de "biqueira" ou a prática do crime de tráfico.

Pois bem. Este é o contexto instalado nos autos.

Com efeito, os policiais que participaram da ocorrência demonstraram muita segurança em seus relatos, apresentando detalhes substanciais que evidenciam conhecimento do caso e precisão quanto à dinâmica fática. Em versões harmônicas e que se completaram, atribuíram ao acusado à prática delitiva narrada na vestibular acusatória.

Segundo se depreende da análise coligida dos depoimentos, os policiais já contavam com informações no sentido de que JONATAS estava realizada o transporte de drogas, abastecendo determinada "biqueira".

Sendo assim, na data dos fatos, estando em patrulhamento, o avistaram caminhando. Então, dele se aproximaram e determinaram que parasse para ser abordado, quando JONATAS esboçou reação corporal anômala, fugindo e, no trajeto da evasão, foi visto arremessando algo na direção de um matagal, posteriormente identificado como sendo um invólucro transparente, contendo 28 pedras de "crack". Abordado, ele estava em poder de certa quantia em moedas (fl. 14).

A fotografia de fl. 13 demonstra que as pedras de "crack", estavam embaladas individualmente, prontas para comercialização.

Incontrovertida toda a dinâmica, porquanto nas duas oportunidades em que fora interrogado, JONATAS confirmou que se evadiu da abordagem e dispensou os

entorpecentes, reconhecendo como sendo dele as 28 pedras de "crack", nos moldes em que apreendidas

Todavia, o contexto não autoriza admitir que aqueles entorpecentes eram para o seu consumo pessoal.

Não era a primeira oportunidade que réu estava sendo abordado, recaindo sobre ele informações quanto ao seu envolvimento no transporte de drogas, com abastecimento de conhecido "ponto" de venda.

Ademais, JONATAS não se mostrou convincente quando alegou ter acabado de adquirir aquelas drogas, no local. Deixou de declinar junto a quem as comprou, o valor pago, além de não ser comum a aquisição daquela quantidade de pedras de "crack", perfeitamente acondicionadas de forma individual, ainda mais inseridas dentro de um invólucro, comumente utilizados para guardar e facilitar o transporte – pedras soltas nos bolsos dificultam a dispersão ao tempo de uma fuga. Outrossim, se somente usuário fosse, não teria dispensando drogas e resistido, daquela forma, à abordagem, após ser alcançado pelos policiais.

Ademais, a condição de usuário veiculada por JONATAS, sequer minimamente comprovada, não exclui, a priori, por si só, a condição de traficante, somente se aplicando a desclassificação quando os elementos permitem cabal aferição nesse sentido, o que não ocorreu na hipótese.

A respeito, confira-se: "(...) Destaco ainda, que muito embora o acusado tente se apresentar como mero usuário, é sabido que nada impede que possam coexistir, numa mesma pessoa, as duas figuras - usuário e traficante - daí, pois, ainda que no caso focado o agente seja usuário, restou demonstrado que o mesmo praticava conduta dirigida para a vontade de traficar ilicitamente substância entorpecente. A rigor, o crime de tráfico de entorpecentes não exige para a sua configuração a venda da substância tóxica a terceiros. A ratio legis pretende antecipar a proteção ao bem jurídico saúde pública, não exigindo a ocorrência de um dano concreto, mas tão somente uma situação onde: ocorra perigo à saúde de um grupo indeterminado de pessoas" (REsp 1708569, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 06/03/2018).

Sendo assim, as circunstâncias fáticas, a prova oral colhida e os elementos se mostram suficientes para a condenação do réu pelo delito de tráfico de entorpecentes, não havendo campo jurídico para a pretendida desclassificação para o crime de porte de entorpecentes (art. 28, caput, da Lei 11.343/06), pena de se afrontar à prova dos autos e a diligente e profissional atuação dos policiais.

O fato de o réu não ter sido preso "vendendo" a droga é matéria irrelevante para a configuração do tipo penal em questão, conforme jurisprudência torrencial a respeito, pois o entendimento francamente vencedor é no sentido de que o perigo de dano em tais casos é presumido de modo absoluto, tendo em vista o perfeitamente conhecido efeito lamentável causado pelo traficante de drogas.

Então, concluo serem válidos e plenamente eficazes os depoimentos ofertados pelos policiais que efetuarão o diligenciamento criminoso, haja vista não contarmos com informações que desabonem ou desprestigiem suas condutas e formas de atuação.

O fato é típico, antijurídico e culpável, não havendo excludentes de ilicitude ou dirimentes de culpabilidade a ser reconhecida, razão pela qual a condenação e imposição da correspondente reprimenda estatal por este delito são medidas que se impõem.

PASSO A DOSAGEM DA PENA.

Atento às diretrizes previstas no art. 59 do Código Penal e da análise de suas Certidões de Eventos (fls. 39 e 40), verifico que o acusado não ostenta

antecedentes conhecidos. Da mesma forma, e também ponderando o art. 42, da Lei de Drogas, não evidencio circunstâncias judiciais desfavoráveis, razão pela qual a pena-base poderá permanecer no mínimo legal

Ausentes circunstâncias agravantes e/ou atenuantes.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento. Os requisitos (cumulativos) para aplicação da causa de diminuição estão taxativamente previstos no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06: ser o agente primário, detentor de bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa.

O referido dispositivo prevê a possibilidade do Juiz (leia-se: poder-dever) em reduzir de 1/6 a 2/3 a pena fixada quando presentes os quatro requisitos cumulativos acima elencados, sem, contudo, estabelecer parâmetros para o exato estabelecimento deste quantum pelo magistrado.

Falhou o legislador. Por tais razões compete a doutrina hodierna e a jurisprudência o interpretarem à luz das peculiaridades de cada caso concreto.

Nesse diapasão é que, no caso em exame há de ser levado em conta a natureza da substância apreendida. Parece-me razoável asseverar que quanto maior o campo de comercialização dela, menor a diminuição da pena.

É nesse sentido, inclusive, o posicionamento da 5ª Turma do C. STJ (HC 136.618/MG, Min. Laurita Vaz, v.u. 01.06.10) e da 5ª Câmara Criminal do E. TJSP (Ap.990.09.170.228-5 – Des. Rel. Marcos Zanuzzi, v.u. j. 10.12.09).

Nesta esteira, considerando a natureza do entorpecente, "crack", com grande procura entre os usuários e altamente letal para a saúde, é que a redução deverá ser feita na proporção de 1/2 (metade).

No que tange ao regime penitenciário, a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e os a ele equiparados foi declarada inconstitucional pelo Col. Pretório Excelso, em 27.6.2012, por ocasião do julgamento do HC 11.840/ES, no Pleno, rel. Min. Dias Toffi.

Assim, a identificação do regime inicial mais adequado à repressão e prevenção dos delitos deve observar os critérios do art. 33, §2º e 3º do Cód. Penal, bem como do art. 42 da Lei 1.343/206, quando se tratar de delitos previstos nessa Lei (STJ HC 272.152/SP rel. Min. Marilza Maynard 6ª Turma J. 10.12.2013).

Mesmo conhecedor do posicionamento do C. STF exarado no HC 118.533 (23.06.16) decidindo não ser o "tráfico-privilegiado" de natureza assemelhada ao crime hediondo, é posicionamento deste julgador que o caso em apreço reclama a imposição de regime INICIAL FECHADO.

Cabe invocar ensinamento daquela mesma Corte Suprema: "A determinação do regime inicial de cumprimento da pena não depende apenas das regras do caput do art. 33 e seu parágrafo 2º do Cód. penal, mas, também, de suas próprias ressalvas, conjugadas com o caput do art. 59 e inciso III (RHC 64.970). E deve ser feita, nos termos do parágrafo 3º do art. 33, com observância dos critérios previstos no art. 59" .

Ora, é de pronta intelecção que a perpetração de tráfico denota personalidade inteiramente avessa aos preceitos ético-jurídicos que presidem à convivência social. Tendo isso presente, deve o juiz sujeitar o agente ao mais severo regime prisional.

Acresce ponderar que a concessão de regime aberto ou semiaberto ao autor de tráfico ilícito de substância entorpecente desvitaliza a eficácia intimidante da pena,

tornando-a inócua, mormente frente ao seu retorno precoce à sociedade, com a sensação de Justiça banalizada.

Pode o juiz determinar o cumprimento da pena em regime fechado, tendo em vista a periculosidade do agente na prática do crime, uma vez que a concessão de regime mais brando é mera faculdade conferida ao julgador, conforme interpretação do art. 33, §3º, do CP .

Lembro, por fim, que a imposição coletiva vinculante quanto à vedação de fixação do regime inicial fechado para cumprimento da pena imposta aos condenados pelo crime de tráfico na modalidade privilegiada, determinada pelo voto monocrático de lavra do E. Relator Ministro Rogério Schietti Cruz (6ªT do C. STJ) em sede de HC nº 596.603/SP, foi CASSADA pela r. decisão exarada pelo Exmo. Ministro do C. STF, Alexandre de Moraes, ao tempo do julgamento do RE nº 1.344.374, em 1º/12/2021, conferindo ao julgador a liberdade de avaliar o regime prisional cabível em cada caso.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal formulada na denúncia para CONDENAR o réu JÔNATAS RODRIGUES DA SILVA, qualificado nos autos, a cumprir pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multas, à razão do mínimo legal, em face da sua hipossuficiência econômica, por infração ao art. 33, caput, §4º, da Lei nº 11.343/06.

INCABÍVEL a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Não se desconhece que em 01.09.2010 o Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte do Poder Judiciário, decidiu pela inconstitucionalidade da vedação legal à substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nos crimes regulados na Lei Federal nº 11.343/2006. O emblemático leading case coube ao "Habeas Corpus" nº 97.256, impetrado pela Defensoria Pública da União no município de Porto Alegre-RS.

Também não passa despercebido que o Senado Federal, recentemente, promulgou no dia 15 de fevereiro a Resolução nº 05 de 2012, suspendendo, nos termos do art. 52, inciso X, da Constituição Federal, a execução da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas).

Todavia, salvo raríssimas e excepcionais situações, a condição de traficante inviabiliza o agraciamento do agente com a substituição em voga, pois o comercializador de drogas, desprovido de senso moral, destruidor de lares e famílias, não preenche os requisitos subjetivos estampados em lei.

O tráfico de drogas apresenta lucros incalculáveis e prejuízos incontáveis à ferida sociedade, tratando-se de mercancia vil, de intensa potencialidade lesiva para a saúde pública e para a sociedade.

Tal constatação vai de encontro com o requisito previsto pelo inciso III, do artigo 44, do Código Penal, exigido, cumulativamente a outros, qual seja, "os motivos e circunstâncias do crime indicarem que essa substituição seja suficiente".

Nesse sentido:

"Não parece razoável que o condenado por tráfico de entorpecentes, seja ele de pequeno, médio ou grande porte, seja beneficiado com essa substituição, porque, em todas as suas modalidades, trata-se de delito de extrema gravidade e causador de inúmeros males para a sociedade, desde a desestruturação familiar até o incentivo a diversos outros tipos de crimes gravíssimos, que, não raro, têm origem próxima ou remota no comércio ilegal de drogas, sem falar do problema de saúde pública em que

já se transformou" (HC 203.403/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 5ªT, j. 21/06/2011, DJe 01/07/2011).

Aliás, bem ressaltou o Eminentíssimo Desembargador Ricardo Tucunduva, "... o tráfico de drogas é delito incompatível com tais benefícios, podendo o legislador, então impor maior rigor na sanção aplicada aos seus infratores, em prol dos interesses da população ordeira e trabalhadora de nosso país..." (TJSP - 6ª Câmara de Direito Criminal, Ap. nº 0000472-64.2011.8.26.0115, j. 02.02.12).

E, ainda, sobre a índole e personalidade de pessoas voltadas para o comércio ilícito de substância entorpecente atentemo-nos para o fato de que o "... traficante de entorpecente é indivíduo desprovido de sensibilidade ética-moral, guiando-se apenas pelo lucro fácil, arrastando para o mal milhares de jovens, contribuindo para a deterioração da saúde alheia, levando desespero e trauma aos familiares desses jovens. Lares são destruídos, sequelas enormes não somente nos jovens atingidos pelas garras desses impiedosos traficantes, como também a seus genitores .

Ademais, não nos parece ter sido a intenção precípua do Poder Constituinte Originário conceder beneplácitos a crimes equiparados aos hediondos, cujo tratamento jurídico merece maior rigorismo.

A meu sentir, respeitado judicioso entendimento em sentido contrário, seria ilógico substituir penas privativas de liberdade para impor sanções restritivas de direitos a condenados por crimes hediondos ou equiparados a eles, sob pena de se esvaziar o tratamento mais rígido que a Lei buscou imprimir, fortalecendo a política criminal voltada a inibir a mercancia espúria de estupefacientes, que, a propósito, propaga sempre outras práticas delitivas execráveis que tanto devastam o país, notadamente de índole patrimonial.

O réu respondeu ao presente feito em liberdade. Ausentes os fundamentos da prisão preventiva (art. 312, caput, §2º do CPP), permito-lhe aguardar solto a fase recursal (art. 387, §1º, CPP).

Autorizo a destruição das substâncias entorpecentes apreendidas que ainda não tenham sido incineradas, oficiando-se.

Com fundamento no art. 63, §1º, da Lei nº 11.343/06, decreto o perdimento do importe numerário apreendido (fl. 72), em favor da União, expedindo-se o necessário.

Custas na forma da lei.

Oportunamente, expeça-se carta de guia de execução, anote-se a condenação definitiva no Sistema Informativo Oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD, nos termos do Provimento nº 33/2012, da E. Corregedoria Geral de Justiça (art. 372 das NSCGJ).

Transitado em julgado, expeça-se mandado de prisão, constando regime inicial fechado.

P.R.I.C.

Amparo, 30 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA